

1501177-15.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501177-15.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501177-15.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175078/2022 - DEL.POL.S.LOURENÇO DA SERRA, 25820563 - DEL.POL.S.LOURENÇO DA SERRA, 2175078 - DEL.POL.S.LOURENÇO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL GRANDAL LEMES RODRIGUES e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

ODAIR ANTÔNIO DE MORAES e NATANAEL GRANDAL LEMES RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 87/89).

Oferecida a denúncia (fls. 89/90), esta foi recebida (fls. 106) e os requeridos citados.

Após a apresentação de defesas escritas (fls. 183/185 e 192/193) o recebimento da denuncia foi ratificado (fls. 186 e 198).

Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e interrogados os acusados.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há questões preliminares a apreciar.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, de fato, praticou o delito que lhe é imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria é indubitosa, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 38/41), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelas fotografias (fls. 29/37), pelos laudos químico-toxicológico (fls. 26/28 e 172/174), que atesta pelos resultados positivos para cocaína, pelo relatório final (fls. 76/78), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Policiais Civis Carlos Henrique Prudente, Rodrigo Aparecido Soares da Silva e Valdir Cardoso de Sá, quando inquiridos em juízo, disseram que estavam na delegacia e receberam denúncia de que pessoas estavam embalando drogas para o comércio no local dos fatos.

Diante disso rumaram até o recinto indicado, valendo-se de uma viatura descaracterizada, onde fizeram breve campana e verificaram que os réus estavam dentro do imóvel. Visualizaram pela janela que os acusados manuseavam drogas.

Asseveraram que, então, ingressaram na residência e encontraram ambos os réus embalando drogas. Na ocasião, os requeridos confessaram que praticavam o ato para terceiros. Odair era o proprietário do imóvel e o cedeu para a prática, do fato.

E as falas dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão

ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

"Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum" (in "Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

As testemunhas arroladas pelas defesas, Ademir de Lima Alvarenga, Edson Gregório dos Santos, José Reis Santos e Edelcio Pires, quando ouvidos em juízo, disseram, em resumo, que os acusados trabalham e são usuários de drogas. Não sabem do envolvimento dos acusados com o crime.

Os réus Natanael e Odair, quando interrogados, confessaram a traficância, dizendo que realmente estavam embalando drogas, tendo Natanael esclarecido que foi contrato por terceira pessoa, a qual o acusado não conseguiu identificar.

Pois bem.

A imputação Ministerial, quanto à tipicidade da conduta dos acusados, é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que os réus, de fato, estavam a praticar a traficância, fato, inclusive, confesso por ambos.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte da ré, na medida em que guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ora, os entorpecentes, em considerável quantidade, eram guardados e levados pelos réus, que os detinham especialmente para o fim de cometer a traficância.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram uníssonos e harmônicos ao descreverem as diligências realizadas durante o ocorrido.

Deveras, "os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder dos acusados se amolda perfeitamente aos tipos penais descritos na exordial acusatória, sendo suas condenações quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno ODAIR ANTÔNIO DE MORAES e NATANAEL GRANDAL LEMES RODRIGUES, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase da dosagem não há nada a ser considerado.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), motivo pelo qual reduzo as penas dos acusados em 1/6, anotando-se, contudo, o teor da Súmula 231 do STJ, no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

E, na terceira fase, não há nada a ser considerado.

Ainda, os acusados não têm direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

O fato de os requeridos terem praticado o ato em concurso e porque as drogas seriam destinadas ao abastecimento de pontos de venda indicam que estão efetivamente inseridos em atividade organizada, pois não é crível que possuísem elevada quantidade de drogas que estavam sendo porcionadas sem que gozassem de certo prestígio ou tivessem envolvimento à criminalidade organizada.

Deveras, "porque diante da apreensão de considerável quantidade de drogas, inequivocamente destinadas ao comércio, admitindo-se a atividade ilícita, o delito cometido se afigura como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não há, ainda, "livre concorrência" ou "empreendedorismo" no tráfico. Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles, ou não tivesse com eles algum vínculo".

Tais fatos demonstram que os acusados têm se dedicado à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

"A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas".

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se

conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)”. (TJ/SP; Ap. 00033339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, chego à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para cada réu.

O regime inicial do cumprimento de pena para ambos os réus é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada e das circunstâncias do crime.

Deixo de aplicar o disposto na Lei nº 12.736/2012, ressalvando que o tempo de prisão em flagrante ou preventiva será oportunamente considerado para fins de detração. Ademais, este juízo de conhecimento não possui dados concretos para análise dos requisitos subjetivos e objetivos para progressão ou outro benefício da fase executória.

Infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, pois não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do réu, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juizes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que “diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova

consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão." Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão do "sursis".

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direito" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Impossível a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento de dinheiro e objeto apreendidos, se o caso.

Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão dos acusados.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a

manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas “ex lege”.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA